المملكة العربيّة السعوديّة

وزارة التعليم العالي

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة

كلية الشريعة

دراسة فقهيّة حول القاعدة" لا ضرر ولا ضرار " وتطبيقاتها.

إعداد

عبدو فارح رياله الجيبوتيّ

إشراف

د. عيسى بن محمد العويس

أستاذ في كليّة الشريعة

ووكيل لمراكز الخارجيّة

في كليّة الشريعة

العام الدّراسيّ

1442-1441

الإستهلال

قال تعالى ((وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)) التوبة (122)

الإهداء

أهدي هذا البحث المتواضع الذي جمعته بشق النفس والكد مع قلة بضاعتي العلمية وضيق الوقت الى اللذين ربياني صغيرا أمي وأبي حفظهما الله لي ورعاهما وسدد خطاهما وجعل جنة مثواي ومثواهما .

وإلى عمّي الذي هو بمثابة أبي والذي كان لي سببا أن ألتحق بالمعهد الإسلامي في جيبوتي.

وإلى مشايخي الأعزاء وأساتذتي الفضلاء الذين كانوا في مساندتي ومضافرتي بين فينة وأخرى لرفع معنوياتي كطالب علم.

والى زملائي في الدراسة وأصحابي في الدرب وأصدقائي في الطلب.

أهديكم هذا البحث الزهيد المرقع كثوب خرق لقلة زاد صاحبه وخمول ذاكرته وأسأل الله أن يغدق عليّ وعليكم شآبيبا من رحماته وفيضا من بركاته انه وليّ ذلك والقادر عليه.

شكر وتقدير

يسرّني أن أشكر بعد الله المملكة العربية السعوديّة, حاملة راية التوحيد, وناصر السنة في أنحاء العالم الإسلامي, ومضادة الشرك والمشركين, وقامعة البدعة والمبتدعين, والله لولا الله ثم المملكة العربيّة السعوديّة لما عرفنا التوحيد وأهل التوحيد, وما عرفنا الشرك ووسائله, وإنّما كان ذلك بعد الله بفضل مملكة العربيّة السعوديّة حرسها الله من كل سوء ومكروه ولا أنسى أن أشكر جميع أساتذي في المعهد الإسلامي سابقا ولاحقا, وأخصّ بالشّكر والتقدير أستاذي ومشرفي د . عيسى بن محمد العويس حفظه الله ورعاه على مساندته وإرشاده لي بالنصح والتصحيح, وأشكر أيضا أ . علي القرني وكيل مراكز الإختبارات في الخارج على تنبيهاته القيّمة التى يتحفنا بها الى الآن وأخيرا نسأل الله أن يوفّقنا لما يحبّه ويرضاه وينجينا من الآفات ما ظهر منها وما بطن.

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما كثيرا وبعد:

فإن علم الشرعي على عمومه من أفضل العلوم, وأشرفه على الإطلاق علم التوحيد الذي هو معرفة الله وهو العلم الّذي يسمّيه بعض العلماء "فقه الأكبر" وثانيه في الرتبة علم الفقه وهو المسمّى "فقه الأصغر" وكلاهما علمان نافعان ناجعان متلازمان, إلا أنّ القارئ أحدهما في بعض الأحايين يحسب أنّ الذي يقرؤه هو أفضل من غيره وذلك لعلوّ مكانهما وعظم شأنهما, وإنّ علم الفقه مع مرتبته الثانية إلّا أنّه علم عظيم القدر, كثير النفع , جمّ الفوائد, وهو العلم الوحيد الذي يبيّن الحلال من الحرام, والحرام من الحلال, وبه تتعلق أركان الإسلام بعد نطق الشهادة, وإنّ من أفضل فروعه وأحسن نتائجه علم القواعد الفقهية وهو نتيجة جهد مضن مستمر إلى الآن ومتتبّع لفروع الشريعة في أبواب الفقه, وإنّه علم يُسَهِّل المصاعب, ويطوي المسافات, ويحصر الفروع, ويقيّد الشوارد في سلك واحد, وله مصنفات كثيرة توجد في مظانها, والمجال فيه واسع, وعلى الرغم من ذلك أودّ أن أكره على نفسي القيام في خوض غمار القواعد الفقهية, وأنوي خصوصا أن أقوم دراسة حول قاعدة عظيمة من القواعد الكبري وهي القاعدة" لا ضرر ولا ضرار" وهذه الدراسة عبارة عن بحث جامعيّ وأقسّم هذا البحث إلى فصلين ومباحث تندرج تحت هذين الفصلين وهي كالتالي:

الفصل الأول: وفيه مبحث واحد .

المبحث الاول: ويشتمل هذا المبحث على أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف القاعدة لغة واصطلاحا .

المطلب الثاني: تعريف الفقه لغة واصطلاحا .

المطلب الثالث: تعريف "القاعدة الفقهية" باعتبارها علما ولقبا لهذا الفن.

المطلب الرابع: حجية القواعد الفقهية.

الفصل الثاني: وفيه مبحث واحد:

المبحث الأول: ويشتمل هذا المبحث على خمسة مطالب:

المطلب الأول: يشتمل تمهيد للقاعدة وأهميتها

المطلب الثاني: تعريف القاعدة لغة واصطلاحا . وشرحها إجمالا.

المطلب الثالث: أصل القاعدة وأقوال العلماء في الحديث وأدلة القاعدة .

المطلب الرابع: القواعد المندرجة تحت القاعدة.

المطلب الخامس: تطبيقات القاعدة

وأخيرا أسلك على منوال هذه الخطّة, وأرجو من الموفّق تسهيل المصاعب, وتيسير الموارد, والعون على تحصيل الفوائد, وتقييد الشوارد, لِيَسْهُل عليّ سوقها في موردها, وقيدها في مربطها, وأسأل الله التيسير في كل أمر نابه التعسير.

الفصل الأول: ويشتمل على تعريف القاعدة وفيه مبحث واحد.

المبحث الأول: ويشتمل على أربعة مطالب.

المطلب الأول: تعريف القاعدة لغة واصطلاحا .

المطلب الثاني: تعريف الفقه لغة واصطلاحا.

المطلب الثالث: تعريف "القواعد الفقهية" باعتبارها علما ولقبا لهذا الفن.

المطلب الرابع: حجية القواعد الفقهية.

المطلب الأول

القاعدة في اللغة أساس الشيء، وجمعها قواعد، وهي أسس الشيء وأصوله، سواء كان حسياً كقواعد البيت، أو معنوياً كقواعد الدين أي دعائمه.
وقد جاء هذا اللفظ في القرآن الكريم، قال تعالى: ((وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل)) البقرة (127).
وقوله تعالى: (فأتى الله بنيانهم من القواعد)) النحل(26). فمعنى القاعدة في الآيتين الأساس وهو ما يرفع عليه البنيان، فكل ما يبنى عليه غيره يسمى قاعدة.

وقال ابن منظور "والقاعدة: الأس ,والقواعد: الأساس ,وقواعد البيت :أساسه."(١).
وقال ابن فارس(ت 395هج):"القاف والعين والدال أصل مطرد منقاس لا يخلف ,وهو يضاهي الجلوس ,وإن كان يتكلم في مواضع لا يتكلم فيها بالجلوس."(٢).

وقال الزجاج (ت 311هج):" القواعد أساطين البناء التي تعمده, وقواعد الهودج خشبات أربع معترضة في أسفله تركب عيدان الهودج فيها."[٣].

والمرأة المسنة تسمّى "قاعدة" وفي التنزيل: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا) [النور: 60]، قال الزجاج رحمه الله في تفسير هذه الآية: هن اللواتي قعدن عن الزواج[٤] وسواء قعدن عن الزواج وصبرن عنه أو كبرن وانقطع منهنّ الحيض.

وقال يعقوب الباحسين :" وقد ذكرت المعاجم اللغوية في هذه المادة كلمات متعددة يبدو من ظاهرها الخلاف ,ولكنها ,عند تأملها ,نجدها تعود إلى المعنى الذي ذكرناه(الثبات والاستقرار) ولو بضرب من التأويل ,كقعيدة الرجل أي امرأته ,وامرأة قاعد عن الحيض والزواج ,والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ,ملتفتا في ذلك إلى قعودهن واستقرارهن في بيوت آبائهن أو أوليائهن ,ومنه قوله تعالى (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا)[النور: 60] كما أن امرأة الرجل تسمى قعيدة لثبوتها واستقرارها في بيت زوجها)[٦].
وقد استتبّ معنى اللغوى العام المراد به لكلمة" القاعدة" الأساس نظرا لانتباء الأحكام عليها كما أن الحيطان مبنيّة على الأسس، وهذا المعنى هو الذي دارت عليه تعاريف العلماء قاطبة رغم تعددها وتفاوت عباراتها كما هو جليّ من مضامين تعاريفهم.

١- لسان العرب 291/5
٢- معجم مقاييس اللغة
٣- التعريفات ص 171
٤- سورة النور رقم الآية-60
٤- القواعد الفقهيّة

وأمّا القاعدة اصطلاحا: فقد تعددت تعاريف العلماء في اصطلاح القاعدة وكل أدلى دلواه بما حبته قريحته وسنذكر بعض منها لا الكل.

قال أبو البقاء الكفوي رحمه الله بأنها: ((قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها))[١].

وقال الجرجاني والإمام المناوي رحمهما الله بأنها: ((قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها))[٢].

وقال الفيومي رحمه الله بأنها: ((الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته))[٣].

قال أبو عبدالله المقرِّي: " كل كليّ أخصُّ من الأصول وسائر المعاني العقليّة, وأعمُّ من العقود وجملة الضوابط الفقهيّة الخاصة."(4)

وقال الحمويّ: "هي حكم أغلبيٌّ ينطبق على معظم جزئياته."(5)

وعرّفها بعض المتأخرين بأنها: حكم أغلبي يتعرّف منه حكم الجزئيات الفقهيّة مباشرة.

قال الدكتور محمد الروكي: "وهكذا نفهم....أنّ المعنى الإصطلاحي العام للقاعدة هو اندراج مجموعة من الجزئيات المتجانسة أو المتشابهة في حكم ما, في أصل وأساس واحد يجمعها, يطلق عليه اسم الكلّيّ أو الكلّيّة."(6).

وكل هذه التعاريف تنصبّ في موضع واحد، ولا اختلاف بينها في المعنى الإصطلاحي إلا أن العلماء اختلفوا يسيرا كون القاعدة قضية كلية أو أمرا أكثريّ أغلبيّ، ولا مشاحة في ذلك.

---

(1) الكليّات لأبي البقاء الكفوي1156
(2) التعريفات 219 والتوقيف على مهمّات التعاريف 569/1
(3) المصباح المنير للفيومي, 700
(4) القواعد الفقهيّة ج212/1
(5) غمر عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر51/1
(6) قواعد الفقه الإسلامي ص 108

المطلب الثاني

اختلف الفقهاء في تعريف معنى الفقه في اللغة وعبرّ كل واحد منهم تعريفا حسب فهمه للمراد اللغوى لمعنى الفقه، لكن عند تأمل في مضامين كل هذه التعاريف يعرف ذو الفطن أن الإختلاف في التعبير لا في الأصل ونذكر بعض منها باقتضاب:

الفِقْهُ في اللغةِ هُوَ: الفَهْمُ، يقال: أُوتِيَ فلانٌ فِقْهاً فِي الدّين؛ أَي: فَهْماً فِيهِ(1). ومن ذلك: قوله تعالى: (فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً) النّساء (78). أي: لا يكادون يفهمون.
ومنه ايضا قوله تعالى: (واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي) طه (27-28) أي: يفهموا قولي.
ومنه قوله تعالى: (قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول) هود (91). أي: ما نفهم كثيراً من قولك، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: " نضَّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما وعاها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ".(رواه الإمام في مسنده وأبوداود وابن حبّان والخطبيب).
ومنه دعاء النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لابن عباس: اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ رواه البخاري (143)، ومسلم (2477)

وقال ابن فارس المتوفي سنة 395هـ وهو يعرّف معنى الفقه في اللغة "فقه الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم به، تقول فقهت الحديث أفقهه، وكل علم بشيء فهو فقه، يقولون لا يفقه ولا ينقه، ثم اختص بذلك علم الشريعة فقيل لكل عالم بالحلال والحرام فقيه، وأفقهتك الشيء إذا بينته لك"[٢].
وقيل الفقه بمعنى: الفطنة والذكاء، ومنه ما ورد في الأثر أَنَّ حُذَيْفَةَ وَسَلْمَانَ رضي الله عنهما، قَالاَ لِامْرَأَةٍ أَعْجَمِيَّةٍ: أَهَاهُنَا مَكَانٌ طَاهِرٌ نُصَلِّي فِيهِ؟ فَقَالَتْ: طَهِّرْ قَلْبَك وَصَلِّ حَيْثُ شِئْت، فَقَالَ: أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: فَقِهْت»(3)
ومن النكت التي نص عليها ابن حجر في المعنى اللغوي للفقه ما أورده في الفتح فقال: «يقال فقه بالضم إذا صار الفقه له سجية، وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقه بالكسر إذا فهم»

وفي الاصطلاح: هُوَ الْعِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ، الْمُسْتَمَدَّةِ مِنْ الأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ.[٣].

وقيل: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.[٤].

وعرّفه الإمام الحرمين بأنه: مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي طَرِيقُهَا الِاجْتِهَادُ" [٥].

والأحكام الشرعية هي: الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل.

---

[١]"تهذيب اللغة" (5/ 263).
[٢]] مقاييس اللغة 4/ 442 جـ21 تحقيق عبدالسلام محمد هارون، مصطفى البابي الحلبي.
[٣] الموسوعة الفقهية" (1/ 13) .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 122/7 وعبدالرزاق 412/1
[٤] كتاب غاية السول إلى علم الأصول ص30.
[٥] متن الورقات

المطلب الثالث

تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علما ولقبا لهذا الفن

تعددت تعاريف الفقهاء في قاعدة الفقهيّة وكل عبّر حسب رأيه وهذه بعض تعاريفهم:

قال التهانوي: "أمر كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه"[1].
وعرفها التاج السبكي بقوله: "القاعدة الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه"[2].
وقال الإمام أبو عبد الله المقري: بأنها "كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود، وجملة الضوابط الفقهية الخاصة". [3],
وقال الجرجاني " قضية كليّة منطبقة على جميع جزئياتها".[4].
وقال الحموي رحمه الله بأنها: "حكم أكثري لا كلي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه" [5].
وقال في تهذيب الفروق: " ومن المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبيّة."(6)
وقال أبوسعيد الخادمي : "حكم ينطبق على جميع جزئياته ليُتعرف به أحكام الجزئيات" [7].
وقال الجلال المحلّي : "قضية كلية يُتعرف منها أحكام جزئياتها" [8].
وقال ابن النجّار : "صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها" [9].
وقال البهوتي : "أمر كلي منطبق على جزئيات موضوعه" [10].

ومنشأ الخلاف بين الفقهاء في تعريف "القاعدة الفقهيّة" يمكن حصره أنّ من قال أغلبيتها نظر إلى وجود المستثنيات في كل قاعدة' ومن قال بأنّها كليّة نظر إلى أصل القاعدة, ولكن العلماء مع ذلك قالوا: إنّ كون الإستثناء في القاعدة لا ينقض كليّة تلك القاعدة.

---

[1] كشف اصطلاحات الفنون ٥/ ١١٧٦-١١٧٧.
[2] المواهب السنيّة ص ٢٨.
[3] قواعد المقري ١/٢١٠ .
[4] التعريفات للجرجاني ص177
[5]غمر عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر ١/٥١.
(6) تهذيب الفروق ج36/1 حاشية الفروق.
[7] مجامع الحقائق ص 305 (خاتمة في القواعد الفقهية).
[8] شرح جمع الجوامع للجلال الدين المحلي ١/٢١.
[9] شرح الكوكب المنير لابن النجار ١/٤٤.
[10] كشّاف القناع للبهوتي ١/١٦

المطلب الرابع

حجية القواعد الفقهيّة

لا يخفى على كل ذي لب ما للقواعد الفقهية من نفع عظيم وقدر جسيم, وقد ناقش العلماء قديما وحديثا حجّية هذه القواعد, وانقل لكم باختصار بعض من أقوال العلماء في قضية حجية القواعد الفقهيّة لأحيلكم عليها وتبرأ ذمّتي جريا على الحكمة "من أسند فقد احال ومن أحال فقد برئت ذمّته".

أقوال من يرى حجية القاعدة الفقهيّة واعتبارها دليلا شرعيا يجب استدلاله .

يرى بعض العلماء أن القاعدة الفقهية تعتبر دليلا يحتج به إذا كان لهذه القاعدة أصل من الكتاب أو السنة, ومن القواعد التي اعتبر العلماء دليلا يحتجّ به القواعد الكبرى والتى تعتبر بمثابة أدلة شرعيّة وهي:

الأولى: الأمور بمقاصدها.

الثانية: اليقين لا يزول بالشك.

الثالثة: لا ضرر ولا ضرار. وهذه القاعدة هي التي نحن بصدد بحثها.

الرابع: المشقة تجلب التيسير.

الخامسة: العادة المحكمة.

وهناك من العلماء من يضيف عليها قاعدة " الخراج بالضمان ".

وهي قواعد متفق على حجيتها والاستدلال بها ولا يحق للمفتي أن يعارضها في فتواه. وهذا ما صرح به الإمام القرافي من أن حكم القاضي ينقض إذا خالف قاعدة من القواعد السالمة عن المعارضة

ويقول الدكتور السدلان: "والحق أنَّنا إذا استثنينا القواعد التشريعيَّة التي مبناها وأساسها على أدلَّة من الكتاب والسنَّة، فلا يصح الرجوع إلى هذه القواعد وحدها فقط دون نصٍّ آخر أو عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها؛ لأنَّ تلك القواعد على ما لها من قيمة واعتبار كثيرة المستثنيات وأحكامها أغلبيَّة غير مطردة"

ويضيف في نفس الصفحة: "ولهذا؛ فإنَّ هذه القواعد تعتبر دساتير للتفقه لا نصوص للقضاء"(1)

وهذا أيضًا ما قصده الإمام القرافي بقوله: (فإنَّ القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه؛ بل للشريعة قواعد كثيرة جدًّا عند أئمَّة الفتوى والقضاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا."(2)

---

(1)القواعد الفقهيّة الكبرى وما تفرّع عنها ص38

(2)الفروق ج11/2

أقوال العلماء الذين لا يعتبرون القاعدة الفقهية دليلًا:

قال ابن نجيم في الفوائد الزينية، كما نقله عنه الحموي في غمز عيون البصائر: (لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط؛ لأنَّها ليست كليَّة بل أغلبية، خصوصًا وهي لم تثبت عن الإمام بل استخرجها المشايخ من كلامه"(1)

أمَّا تقرير مجلَّة الأحكام العدلية، فجاء فيه ما يلي: (فحكام الشرع ما لم يَقفوا على نقل صريح لا يَحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد، إلَّا أن لها فائدة كلية في ضبط المسائل، فمَن اطَّلع عليها من المطالعين بضبط المسائل بأدلَّتها، وسائر المأمورين يرجعون إليها في كلِّ خصوص، وبهذه القواعد يمكن للإنسان تطبيق معاملاته على الشَّرع الشريف أو في الأقل التقريب)(2) مجلة الأحكام العدليّة ص10 مع شرح علي حيدر المسمّى "درر الحكام شرح مجلة الأحكام."

وقال الشيخ مصطفى الزرقا: "ولذلك كانت تلك القواعد الفقهيّة قلّما تخلو من مستثنيات في فروع الأحكام التطبيقيّة خارجة عنها, إذ يرى الفقهاء أنّ تلك الفروع المستثناة من القاعدة هي أليق بالتخريج على قاعدة أخرى , أو أنّها تستدعي أحكاما استحسانيّة خاصة, ومن ثمّ لم تسوّغ المجلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الإستناد إلى شيئ من هذه القواعد الكليّة فقط دون نصّ آخر خاص أو عام يشتمل بعمومه الحادثة المقضيّ فيها , لأنّ تلك القواعد الكليّة على ما لها من قيمة واعتبار هي كثيرة المستثنات فهي دساتير للتفقه لا نصوص للقضاء."(3) المدخل الفقهي ج2/934-935)

وينبغي أن يعلم أن وجود المستثنيات لا يقدح في كلية القواعد ولا ينقضها,وقد نص العلماء على ذلك:

قال ابن القيم(ت 751هج):"إن شأن الشرائع الكلية أن تراعي الأمور العامة المنضبطة,ولا ينقضها تخلف الحكمة في أفراد الصور."(4).

وقال أبو إسحاق الشاطبي(ت790هج):"إن الأمر الكلي إذا ثبت ,فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا,وأيضا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي ,لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت.....فالكليات الاستقرائية صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات." (5).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت 721هج):"وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره,لا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ,ويمنع مساواته لغيره."(مجموع الفتاوى ج20ص505).قال د يعقوب الباحسين:"وإذا تتبعنا أكثر ما يستثنونه وجدناه لم ينطبق عليه شرط القاعدة ,إذ إنهم يذكرون القاعدة مجردة عن الشروط التي لا بد من تحققها .وقد يكون خروج الجزئيات المذكورة عن القاعدة بسبب وجود مانع فيها.وهذا الأمر ينطبق على جميع القواعد ,وليس القواعد الفقهية وحدها."(6).

---

(1) غمز عيون البصائر ج1/ص37
(2) مجلة الأحكام العدليّة ص10 مع شرح علي حيدر المسمّى"درر الحكام شرح مجلة الأحكام."
(3) المدخل الفقهي ج2/934-935)
(4) إعلام الموقعين,ج2ص68-69
(5) الموافقات ج2ص52-53
(6) القواعد الفقهية ص47

الفصل الثاني: تعريف القاعدة وفيه مبحث واحد .

المبحث الأول: ويشتمل على خمسة مطالب:

المطلب الأول: تمهيد للقاعدة وأهمية القاعدة

المطلب الثاني: تعريف القاعدة لغة واصطلاحا . وشرحها إجمالا .

المطلب الثالث: أصل القاعدة وصحتها وأدلّتها

المطلب الرابع: القواعد المندرجة تحت القاعدة.

المطلب الخامس: تطبيقات القاعدة

المطلب الأول

تمهيد:

هذه القاعدة من القواعد العظيمة التي يطلقها العلماء "القواعد الكبرى" وتدخل في كثير من أبواب الفقه بل وتعالج كثير من القضايا المعاصرة والأحداث المستجدّة, سواء كانت دينيّا أو دنيويّا, حتى قال بعض الفقهاء ان نصف الفقه يندرج تحت هذه القاعدة, ووجه ذلك نعلم يقينا أن شريعتنا الموقّرة لا تخلو إمّا جلب مصلحة أو دفع مضرّة, وهذه القاعدة التي معنا الآن هي القاعدة التي تؤصّل جانب دفع المضرّة, أو تقليلها على الأقل, وتحصيل المصالح وتكميلها.

أهمية القاعدة

ان هذه القاعدة من أكثر القواعد نفعا, وأجلّها قدرا, وأعظمها شأنا, لأنها أساس لمنع الضرر عن النفس والمال, ويبنى عليها كثير من أبواب الفقه كما قال السيوطي رحمه الله :"اعلم أنّ هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه"**(1)**.

قال الحافظ العلائي رحمه الله: "فهذه قاعدة يبنى عليها كثير من أبواب الفقه بكمالها, ومسائل لا تعدّ كثرة".(2).

وقال ابن النجار: " فيها من الفقه ما لا حصر له, ولعلّها تتضمّن نصفه, فإنّ الأحكام إمّا لجلب المنافع أو لدفع المضار, فيدخل فيها دفع الضرورات الخمس: حفظ الدين والنفس والنسب والمال والعرض. وهذه قاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها"(3).

وقال الشيخ أحمد الزرقاء: "يتفرّع على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه ممّا كانت مشروعيته توقيا من وقوع الضرر"(4).

وقال النّدوي: " هذه القاعدة من أهمّ القواعد وأجلّها شأنا في الفقه الإسلامي, ولها تطبيقات واسعة في مختلف المجالات الفقهيّة"(5).

وقال الشيخ صالح السدلان: "هذا الحديث.....المعنونة به هذه القاعدة يعتبر من أهمّ القواعد وأشملها فروعا, وله تطبيقات واسعة في الفقه الإسلامي, وهو أساس لمنع الفعل الضّار, وميزان عند القاضي فب تقرير القضايا, والحكم عليها بالعدل والإنصاف, كما أنّه سند لمبدإ الاستصلاح في جلب المصالح ودرء المفاسد, وهو عدّة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم في تقرير أحكام الشريعة للحوادث"(6).

---

(1)- الأشباه والنّظائر للسيوطي-ص84
(2)- المجموع المذهب 122/1
(3)- شرح الكواكب المنير 443/4
(4)- شرح القواعد الفقهيّة ص114
(5)- شرح القواعد الفقهيّة ص123
(6)- القواعد الفقهيّة الكبرى وما يتفرّع عنها ص494

المطلب الثاني

تعريف القاعدة لغة واصطلاحا

الضرر لغةً كل ما هو ضد النفع ، والضرُّ بالضم الهزال وسوء الحال ومن هنا أتت المَضرَّة ، وهي خلاف المنفعة ، ويرد الضرر أيضاً بمعنى الضيق والنقصان يدخل في الشيء.(1).

وقد وردت لفظ الضرر في الكتاب العزيز وفي مواضع كثيرة منها قوله تعالى ((لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر)).(2).
وكذلك قوله تعالى ((والصابرين في البأساء والضراء)).(3).
وأيضاً قوله تعالى ((وإذا مس الإنسان الضرُّ دعانا لجنبه) (4).
وكذلك قوله تعالى ((وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما))(5).

كما وردت لفظة الضرر في السنة النبوية ، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((لا ضرر ولا ضرار))(6).
وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم ، ((من ضار أضر الله به)) (7).

وقد سئل في " لقاءات الباب المفتوح " للشيخ العثيمين رحمه الله معنى الضرر والضرار والفرق بينهما وأجاب الشيخ بأنّ الضرر: ما كان عن غير قصد، والضرار: ما كان عن قصد، لأن ضرار مصدر ضار يضار ضراراً، ومضارة، كجاهد يجاهد جهاداً، ومجاهدة، فما كان عن قصد فهو ضرار، وما كان عن غير قصد فليس ضراراً، مثال ذلك: إنسان عنده شجرة في بيته يسقيها فانتشرت الرطوبة إلى بيت جاره بدون قصد، هذا نقول فيه: ضرر، وإنسان آخر غرس شجرة وصار يسقيها من أجل أن ينتشر الماء والرطوبة إلى بيت جاره فيتأذى به، هذا ضرار، وكلاهما منفي شرعاً، فالضرر يزال وإن لم يقصد، والمضارة تزال وعليه إثم القصد.[8].

1- لسان العرب ، الجزء السادس ، الدار المصرية للتأليف .
2-الآية ((95)) من سورة النساء .
3-الآية ((177)) من سورة البقرة .
4- الآية ((12)) من سورة يونس .
5- الآية ((113)) من سورة النساء .
6- الموطأ لإمام مالك ج١/٥٦٦ رقم الحديث(١٤٦١) باب القضاء في المرفق.
(7)- رواه أبو صرمة مالك بن قيس المازنيّ, نقله الألباني في صحيح ابن ماجة وحكم بأنّه: حسن
(8)- لقاءات الباب المفتوح (٢٠٢).

وأمّا في الاصطلاح فقد قيل الضرر: بعنى إلحاق مفسدة بالغير مطلقا، والضرار: مقابلة الضرر بالضرر.
وقيل: الضرر: الإسم والضرار: الفعل.
وقيل: هما لفظان بمعنى واحد تكلم بهما جميعا من باب التأكيد. مثل لا شكّ لكثير الشك

وقيل: الضرر: أن تضرّ من لا يضرُك والضرار: أن تضرّ من أضرّ بك من غير جهة الإعتداء بالمثل والإنتصار بالحق.(1).

وفسّره بعضهم: بأن لا يضر الرجل أخاه ابتداءً ولا جزاءً.
وقيل: الضرر فعال بكسر أوّله من ضارَّ ومضارة, وضرار بمعنى ضرّه, واضطرّه إلى كذا بمعنى ألجأه إليه وليس له منه بدٌّ.(2)

وقيل : الضرر: هو الذي لك فيه منفعة وعلى غيرك فيه مضرّة.
والضرر يرجع إلى أحد أمرين: إمّا تفويت مصلحة أو حصول مضرّة من الوجوه.(3)

شرح القاعدة اجمالا

"عبَّر أكثر من كتب في القواعد عن هذه القاعدة بقولهم: (الضرر يزال) وجعلوا ما عبَّرنا به، وهو الحديث دليلاً على القاعدة وأصلاً لها.

ولكن التعبير بصيغة الحديث عن القاعدة أشمل وأعم، حيث يشمل الضرر ابتداءً ومقابلة، وأيضاً يعطي ذلك القاعدة قوة؛ إذ يجعلها دليلاً شرعياً صالحاً لبناء الأحكام عليه باعتبار أنها نص حديث نبوي كريم، بخلاف قولنا الضرر يزال فليس لهذا القول قوة شرعية كنص الخبر"(4)

وإنّ هذه القاعدة من دعائم العظام للشريعة، ويشهد لها نصوص فذّة في الكتاب والسنة، وفقه آثار سلف الأمّة التى تؤيّد هذه القاعدة والتى تنبثق من مشكاة الوحيين سواء كانت نصّا قرآنيّا أو حديثا نبويّا، وقد امتازت هذه القاعدة سعتها كنفها وشمول ديباجها، بحيث يندرج تحتها كثير من أبواب الفقه؛ وبحيث يستطيع طالب العلم أن يعرف من خلالها الحكم الشرعي لكثير من المسائل التى بنته الشريعة لضمان مصالح الناس في العاجل والآجل، وتعتبر هذه القاعدة النبوية أصلا من أصول الدين، وقاعدة عظيمة من قواعد الإسلام.
وهذه القاعدة جاءت لمنع الضرر والضرار معا؛ إذ الضرر يقصد به عدم وجود الضرر فيما شرعه الله من الأحكام لعباده؛ والضرار نهي المؤمنين عن احداث الضرر أو فعله.

---

(1)غمز عيون البصائر ج1/ص188
(2)المصباح المنير للفيومي ج2/ص425
(3)شرح الأربعين النوويّة ص83-84
(4)الوجيز في ايضاح القواعد الفقه الكلية-ص251 – مكتبة الشاملة الحديثة

المطلب الثالث

أصل القاعدة

هذه القاعدة نص حديث نبويّ شريف أخرجه مالك في الموطّأ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا ضرر ولا ضرار".[1].
وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار، من ضارّ ضارّه الله ومن شاقّ شاقّ الله عليه" [2].والشطر الثاني من الحديث ورد في صحيح البخاري وهو " من شاقّ شاقّ الله عليه يوم القيامة".[3].
ولأبي داود في سننه من طريق ابي صرمة أنّ رسول الله عليه وسلم قال" من ضارّ ضارّ الله به، ومن شاقّ شاقّ الله عليه".[4].
ولابن ماجة من طريق فضيل بن سليمان عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قضى أن لا ضرر ولا ضرار". [5].

أقوال العلماء في الحديث[6].

قال الحاكم : صحيح الاسناد على شرط مسلم. وحسّن الحديث ابن الصلاح فقال :هذا الحديث أسنده الدار قطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به وقول أبي داود إنه من الأحاديث التي يدور عليها الفقه يشعر بكونه غير ضعيف .اهـ نقله عنه ابن رجب
وقوى الحديث النووي رحمه الله في الأربعين فقال :له طرق يقوي بعضها بعضا .وتبعه ابن رجب فقال: وهو كما قال .وذكر أن الإمام أحمد استدل به .(جامع العلوم والحكم ص210)ط: الرسالة
كذلك حسن الحديث العلائي فقال :للحديث شواهد ينتهي مجموعها الى درجة الصحة أو الحسن المحتج به. وكذلك حسنه السيوطي
فالأظهر أن الحديث حسن لغيره ,وقد صححه لغيره الألباني رحمه الله (ارواء الغليل 410/3,والصحيحة448/1)وحسّنه الأرناؤوط في تحقيقه لجامع العلوم لابن رجب
أما المضعفون للحديث فمنهم ابن عبد البر حيث قال: لا يسند من وجه صحيح ومنهم خالد بن سعد الأندلسي الحافظ نقل عنه ذلك ابن عبد البر

---

[١] الموطّأ لإمام مالك ج١/٥٦٦ رقم الحديث(١٤٦١) باب القضاء في المرفق- مرسل.
[٢]. المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ج٢/٥٨.
[٣] فتح الباري ج٣/١٢٨.
[٤] عون المعبود ج١٠/٦٤.
[٥] مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للحافظ البوصيري ج٣/٣٣ رقم الحديث(٨٢٧). ط. دار الجنان الثانية.
(6) منقول من ملتقى أهل الحديث

- **أدلة القاعدة**

للقاعدة أدلة مبثوثة في الكتاب والسنة وأقوى دليل لها هو كون نفسها دليل لنفسها، وأحسب أنه من أقوى الأدلة، وكما أن تفسير القرآن بالقرآن من أقوى التفاسير، كذلك كون القاعدة دليل لنفسها من أقوى الأدلة لها وذلك فضل من الله لهذه القاعدة من بين القواعد الأخرى، ومع ذلك سنذكر بعض الأدلة التي تعاضد هذه القاعدة

-من القرآن:

"وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ"[1]. حيث أمر الله المؤمنين الإستعداد لمواجهة الأعداء لدفع الضرر عن المسلمين بأرهابهم وتخويفهم.

- "لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا". [2].

-"ولا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ". [3].

- قوله تعالى: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا) [4].

- قوله تعالى: (وَلَا تُضَارُّوا لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) [5].

- قوله تعالى: (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) [6].

- "وَلَا تَعْتَدُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ"[7]. أيّ ولا ترتكبوا المناهي من المُثْلة، والغُلول، وقَتْلِ من لا يحل قتله من النساء والصبيان والشيوخ، ومن في حكمهم. إن الله لا يحب الذين يجاوزون حدوده، فيستحلون ما حرَّم الله ورسوله.

---

(1)- الأنفال الآية 60.
(2)- محمد الآية 32.
(3)- البقرة الآية 282.
(4)- الطّلاق الآية 6.
(5)- البقرة الآية 231.
(6)- البقرة الآية 233.
(7)- البقرة الآية 190

- ومن السنة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ".(1).

وقوله «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ"(2).

وعن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ((يا عبادي، إني حرمتُ الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا، فلا تظالموا" (3).

وما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه قال «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ» (4).

زعن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعونٌ مَن ضارَّ مؤمنًا أو مكَر به".(5).

---

(1) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(2) رواه مسلم والترمذي

(3) رواه مسلم ٢٦٧٧
(4) سبل السلام٣/١٢١٥.
(5) الترمذي ١٨٦٤

القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة مع مثال لكل قاعدة:

القاعدة الأولى: الضرر يدفع بقدر الإمكان.(1)

التوضيح

الضرر لا يقره الشرع نهائياً، ويجب دفعه قبل وقوعه ما أمكن، لأن الوقاية خير من العلاج، كما يدفع الضرر بقدر الإمكان كلياً إن أمكن، وإلا فبقدر ما يمكن، بأن كان يجبر بعوض فيجبر به، أما إذا لم يمكن دفعه بالكلية، ولا جبره فإنه يترك على حاله.

التطبيقات

1 - شرع الإسلام الجهاد لمقاومة الأعداء، ودفع الضرر منهم.

2 - أوجب الشرع العقوبة على الجاني لقمع الإجرام، فيكون عبرة لغيره.

3 - أقر الشرع حق الشفعة منعاً لضرر الجار أو الشريك.

4 - عفا بعض أولياء القتيل عن القصاص فينقلب نصيب الباقين دية لدفع الضرر عنهم.

5 - يجب ردّ المغصوب عيناً إذا كان سليماً لدفع الضرر عن المالك، فإن ذهبت عينه يجبر الضرر برد مثله إن كان مثلياً، وقيمته إن كان قيمياً، سواء كان ذهاب العين حقيقياً كالطعام إذا أكله الغاصب، أو حكمياً كما إذا كان شاة فذبحها وطبخها، أو حنطة فطحنها.

القاعدة الثانية: الضرر يزال.

هذه القاعدة تفيد وجوب إزالة الضرر ورفعه بعد وقوعه.

من فروع هذه القاعدة وأمثلتها:

إذا سلط إنسان ميزابه على الطريق العام بحيث يضر بالمارين، فإنه يزال، وكذلك إذا تعدى على الطريق ببناء أو حفر بالوعة أو غير ذلك.

وكذلك يضمن المتلف عوض ما أتلف للضرر الذي أحدثه.

وإذا طالت أغصان شجرة لشخص وتدلت على دار غيره فأضرته يكلف رفعها أو قطعها.

وقد شرع كثير من الخيارات في بعض العقود لإزالة الأضرار الواقعة على أحد المتعاقدين، كخيار العيب وخيار الغبن.

---

(1)القواعد الفقهيّة وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة-ص208-المكتبة الشاملة الحديثة.

(2) الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية-ص258- المكتبة الشاملة الحديثة

القاعدة الثالثة: الضرر لا يزال بمثله.(1).

هذه القاعدة تعتبر قيداً لسابقتها، لأن الضرر مهما كان واجب الإزالة، فلا يكون بإحداث ضرر مثله، ولا بأكثر منه بطريق الأولى.

فالشرط إذاً أن يزال الضرر بلا إضرار بالغير إن أمكن وإلا فبأخف منه.

فمن فروع هذه القاعدة وأمثلتها:

لا يجوز لإنسان محتاج إلى دفع الهلاك جوعاً عن نفسه أن يأخذ مال محتاج مثله، كما لا يجوز لمن أكره بالقتل أن يقتل إذا كان المراد قتله مسلماً بغير وجه حق، لأن هذه إزالة ضرر بمثله، بخلاف أكل ماله.

وإذا ظهر في المبيع عيب قديم وحدث عند المشتري عيب جديد، امتنع رد المبيع بالعيب القديم؛ لتضرر البائع بالعيب الحادث، إلا أن يرضى، ولكن يعود المشتري على البائع بالنقصان.

القاعدة الرابعة: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.(2)

-التوضيح

إن الضرر ليس على درجة واحدة، وإنما يتفاوت في ذاته، وفي آثاره، والضرر يجب رفعه لقاعدة: الضرر يزال وقاعدة: لا ضرر ولا ضرار.

ولكن إذا لم يمكن إزالة الضرر نهائياً، وكان بعضه أشد من بعض، ولا بدَّ من ارتكاب أحدهما، فتأتي هذه القاعدة: الضرر الأشد يزال ويرفع ويتجنب بارتكاب الضرر الأخف.

وذلك لعظم الأول على الثاني، وشدته في نفسه، أو لأن الضرر الأول عام يعمُّ أثره، والضرر الثاني خاص وينحصر أثره، فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: " فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها

بقدر الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعاً، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعاً."(3)

---

(1) الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية-ص259- المكتبة الشاملة الحديثة

(2) كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للشيخ محمد مصطفى الزحيلي-ص219

(3) مجموع الفتاوى 343/23.

القاعدة الخامسة: يختار أهون الشريّن.(1)

الآلفاظ الأخرى

- يدفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما.

- إذا تعارضت مفسدتان رُوعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما .

- تحتمل أخف المفسدتين لدفع أعظمهما.

- إذا اجتمع مكروهان، أو محظوران، أو ضرران، ولم يمكن الخروج عنهما

وجب ارتكاب أخفهما.

التوضيح

إن الشريعة جاءت لمنع المفاسد، فإذا وقعت المفاسد فيجب دفعها ما أمكن، وإذا تعذر درء الجميع لزم دفع الأكثر فساداً فالأكثر، لأن القصد تعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، فإذا اضطر إنسان لارتكاب أحد الفعلين الضارين، دون تعيين أحدهما، مع تفاوتهما في الضرر أو المفسدة، لزمه أن يختار أخفهما ضرراً ومفسدة.

لأن مباشرة المحظور لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة، والضرورة تقدر بقدرها.

ومراعاة أعظم الضررين بإزالته، لأن المفاسد تراعى نفياً، والمصالح تراعى إثباتاً.

ومستند هذه القاعدة قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ)(2).

وقال ابن نجيم - رحمه الله: قال الزيلعي في باب شروط الصلاة: ثم الأصل في جنس هذه المسائل أن من ابتلي ببليتين، وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء، وإن اختلفا يختار أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة."(3)

القاعدة السادسة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما .

معنى القاعدة: إن الأمر إذا دار بين ضررين أحدهما أشد من الآخر، فيحمل بأيتهما شاء، وإن اختلفا يختار أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة(4)
وهذه القاعدة المذكورة، وكذلك قاعدة: "إذا اجتمع الضرران أسقط الأكبر للأصغر"، و"الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف"، و"يختار أخفَّ الضررين"، و"يختار أهونَ الشرين" - متحدة المعنى، ليس بينها فرق إلا في صياغة القاعدة

---

(1) كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة-ص226- المكتبة الشاملة الحديثة.
(2) البقرة الآية 217.
(3) - في «الأشباه والنظائر-ص76
(4) الأشباه والنّظائر لابن النجيم ص89

التطبيقات

1-شيخ لا يقدِر على القراءة قائمًا، ويستطيع القراءة قاعدًا فيقعد؛ لأن القعود في النفل - جائز.
2- لو اضطر المحرم وعنده صيد، وميتة، أكل الصيد دون الميتة؛ لأن ضررَه أخف.

القاعدة السابعة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام(1).

التوضيح

يجب رفع الضرر، لقاعدة: الضرر يزال .

وقاعدة: لا ضرر ولا ضرار.

ولكن قد يصعب رفع الضرر نهائياً, وهنا يتفاوت الضرران قطعاً، ويكون أحد الضررين لا يماثل الآخر، في حقيقته، أو في آثاره، فيزال الأعلى بالأدق.

وقد يكون عدم المماثلة لخصوص أحدهما، وعموم الآخر، فيرتكب الضرر الخاص، ويتحمله صاحبه، لدفع الضرر العام الذي يؤثر على المصلحة العامة؛ لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.

التطبيقات

1 - يُحجر على الطبيب الجاهل، والمفتي الماجن، والمكاري المفلس، وإن تضرروا بذلك لدفع ضررهم على الجماعة في أرواحها ودينها ومالها(2).

2 - تزال الغرفة الوطية البارزة، والجناح الداني، والمسيل المضر، إذا كان في طريق العامة وإن كانت قديمة.(3).

3 - يجب نقض الحائط المتوهن على صاحبه إذا كان في الطريق، دفعاً للضرر العام.(4)

4 - يجب قتل قاطع الطريق إذا قتل بأي كيفية كانت بدون قبول عفو عنه من ولي القتيل، دفعاً للضرر العام.(5).

---

(1) كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة-ص235- المكتبة الشاملة الحديثة
(2) الزرقا ص 198، الدعاس ص 26، السدلان ص 535.
(3) الزرقا ص 197، الغرياني ص 159 .
(4) الزرقا ص 197 .
(5) الزرقا ص 197 .

القاعدة الثامنة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

إذا حدث تعارضٌ بين المفاسد والمصالح وكانتا في منزلة ورُتبة واحدة، يقدَّم دفعُ المفاسد على الاعتناء بالمصالح(1).

وهناك قاعدة: "دَفع المفاسِد مُقدَّمٌ على جلبِ المصالِح" وقاعدة "درءُ المفسَدَة أولى مِن جَلب المصلَحَة"وقاعدة ،"دفعُ المفسَدَة أهمُّ مِن تحصيلِ المصلَحَة"

ويقول السيوطي رحمه الله: "إذا تَعارضَت مفسَدةٌ ومصلَحةٌ؛ قُدِّم دفعُ المفسَدةِ غالبًا؛ لأنَّ اعتِناءَ الشارعِ بالمنهِيَّات أشَدُّ مِن اعتنائِه بالمأمورات"[2].

ويقول العزُّ بن عبدالسلام رحمه الله: "إن تعَذَّر الدَّرءُ والتَّحصيلُ فإن كانت المفسَدةُ أعظمَ من المصلَحةِ، درَأنا المفسَدةَ ولا نُبالي بفَواتِ المصلَحة"[3]

ومن أدلة مشروعيتها من الكتاب:

قوله تعالى: (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) [الأنعام: 108].

وجه الدلالة: أن الله منَع المسلمين من أن يسبُّوا آلهة المشركين؛ خوفًا من مفسدةِ سبِّ المشركين لله تعالى[4].

ويُثاب المرء إذا التزم بهذه الآية الكريمة[5]؛ فقد نَهى الإسلام عن سب آلهة المشركين مع ما فيه من المصلحة، ولكن مفاسدها أكبر.

وقال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) [البقرة: 219].

وجه الدلالة: أن الله أعلَم المسلمين بأنَّ الخمر فيها مصالحُ ومَفاسد، ولكن مفاسدها أكثر من منافعها[6]؛ لأن مِن مفاسد الخمر أنَّها تزيل العقل وتؤدِّي للصد عن سبيل الله تعالى[7].

"حرَّمَهما؛ لأنَّ مفسدتَهما أكبر من منفعتهما؛ أمَّا منفعة الخمر فبالتِّجارة ونحوها، وأمَّا منفعة الميسر فبما يأخذه القامرُ من المقمور، وأمَّا مفسدة الخمر فبإزالتها العقولَ، وما تُحدِثه من العداوة والبغضاء، والصَّدِّ عن ذكر الله وعن الصَّلاة، وأمَّا مفسدة القِمار فبإيقاع العداوة والبغضاء، والصَّدِّ عن ذِكر الله وعن الصَّلاة، وهذه مفاسدُ عظيمةٌ لا نسبةَ إلى المنافع المذكورة إليها"[8]

---

(1) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليّة-ص265

(2) الأشباه والنظائر ج87/1

(3) قواعد الأحكام ج98/1

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (2/ 58).

(5) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، (12).

(6) الجامع لأحكام القرآن، (3/ 60).

(7)] قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ للعز بن عبدالسلام، (1/ 83).

(8) قواعد الأحكام، (1/ 98).

ومن السنة النبوية:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((دَعوني ما تركتُكم، إنما هلك مَن كان قبلكم بسؤالهم، واختلافِهم على أنبيائهم، فإذا نهيتُكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم))[1].

وجه الدلالة: أن من يلتزم بما أمر الله ويجتنب نواهيه فقد أطاعه، فما أمر الله به ففيه مصلحةٌ لعباده، وما نهى عنه ففيه مفسدة يجب اجتنابها[2]

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والجلوسَ في الطرقات))، فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بدٌّ؛ نتحدث فيها، فقال: ((إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقَّه))، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: ((غضُّ البصر، وكفُّ الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر))[3].

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهى عن الجلوس في الطرقات؛ لأن مفاسدَه أكثرُ من مصالحه، ومن جلَس فعليه الالتزام بآداب الطريق التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم[4].

وهذا يوضِّح لنا أن كل عمل فيه مصالح ومفاسد، فإذا تساوَت المصالح والمفاسد في نفس المرتبة، يقدَّم درء المفسدة على المصلحة.

ويستثنى من هذه القاعدة أنه قد تُقدَّم المصلحة على المفسدة أحيانًا؛ لغلبة المصالح على المفاسد، كالصلاة إذا اختلَّ شرطٌ من شروطها كستر العورة مثلاً فهي مفسدة؛ ولكن مصلحة الصلاة أعظمُ، فتُقدَّم مع وجود هذه المفسدة[5].

ولذا لا تطبق هذه القاعدة إلا إذا تساوَتِ المصالح والمفاسد في المنزلة؛ لأنه لا يمكن أن نأتي بعمل كله مصالح أو كله مفاسد، وإن وجَدناه فنادرًا ما يحدث.

قال القرافي رحمه الله: "لو اختلط موتى المسلمين بالكفار، فإن كان عددُ المسلمين أكثر أو تساووا صلى عليهم"[6].

---

(1) البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنة رسول الله، رقم الحديث (6744).
(2) عمدة القاري، شرح صحيح البخاري، (35/ 392).
(3) البخاري، كتاب الاستئذان رقم الحديث (5761).
(4) نيل الأوطار (5/ 374)، فتح الباري (5/ 113).
(5) الأشباه والنظائر (1/ 87).
(6) الذخيرة للقرافي، (2/ 472)

القاعدة التاسعة: القديم يترك على قدمه(1)

التوضيح

القديم هو الذي لا يوجد مَنْ يعرف أوله

ويكون له وجه شرعي، فإنه يترك على قدمه إلا إذا قام الدليل على خلافه

فإذا كان التنازع فيه قديماً فتراعى حالته التي هو عليها من القديم، بلا زيادة ولا نقص، ولا تغيير ولا تحويل.

ولا يجوز تغييره عن حاله أو رفعه إلا بإذن صاحبه؛ لأنه لما كان من الزمن القديم على هذه الحالة المشاهدة فالأصل بقاؤه على ما كان عليه، ولغلبة الظن بأنه ما وضع إلا بوجه شرعي، لحسن الظن بالمسلمين، وعلى هذا صا كان في أيدي الناس وتصرفاتهم قديماً من أشياء ومنافع ومرافق مشروعة في أصلها، يبقى لهم كما هو، ويعتبر قدمه دليلاً على أنه حق موضوع بطريق مشروع، فلا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف.

ولو ادعى أحد الخصمين الحدوث، وادعى الآخر القدم، فالقول قول من يدعي القدم، والبينة بينة من يدعي الحدوث، والمراد بالقديم الشيء المشروع، أما القديم غير المشروع، فإنه يزال حسب القاعدة الأخرى

."الضرر لا يكون قديماً"

التطبيقات

لو كان لدار أحدٍ ميزاب على دار غيره، أو كان لداره مسيل ماء، أو بالوعة أقذار في أرض الغير، أو كان له ممر إلى داره مثلاً في أرض الغير، أوكان بعض غرف بيته راكبة على جدران جاره من القديم، ولا يعرف أحد من الحاضرين مبدأ

---

(1) كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة-ص251- المكتبة الشاملة الحديثة

تطبيقات القاعدة

من أمثلة تطبيقات هذه القاعدة على الواقع الطبي:

- تفعيل نظام الحجر الصحي لدفع ضرر الأمراض المعدية عموما مثل مرض فيروس كورونا الذي أبكى العالم كله, وأعجز الدول المتطورة .

- حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم ولو لم يثبت عليهم جرم معين بطريق قضائي دفعا لشرهم .

- دفع انتشار الأمراض بقدر الاستطاعة.وذلك بتعميم الإجراءات الوقائية لدفع الإصابة بالأمراض المختلفة ، وبالحجر الصحي على المرضى والحاملين للمرض.

ومن جانب تطبيقات طلب المرأة طلاقها من زوجها(1)

لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطلب الطلاق من زوجها, لكن لا بد من عمل قيد لتطبيق هذه القاعدة على مسألتنا هذه، وذلك بأن نزيد على القاعدة قيداً وهو: في غير ما بأس، يعني: أنه لو وجد بأس فيجوز للمرأة أن تطلب الطلاق، وتدخل تحت القاعدة: لا ضرر ولا ضرار.

وكيفية تطبيق هذه القاعدة على هذه المسألة أن تقول: إن المرأة التي تطلب الطلاق في غير ما بأس قد أوقعت الضرر بزوجها، والقاعدة تقول: لا ضرر ولا ضرار.

وأنواع الضرر هنا كثيرة: منها أنها تعرضه للفتنة، ومنها: أنها تكسر قلبه فتوقع عليه الظلم، ومنها: أنها تجعله يظن الظنون بكل المسلمات أو الملتزمات أنهن كذلك، فنقول لها لا يجوز أن تطلبي الطلاق فتضيعي وتضيعي، والقاعدة تقول: لا ضرر ولا ضرار، إلا أن تجيب وتقول: إن هنالك بأساً، فيباح لها.

والدليل: ما جاء صريحاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم: **عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ)(2)**

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: (إن المختلعات هن المنافقات)(3)

ومن صور تطبيق هذه القاعدة مسألة: طلب المرأة طلاق أختها: وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا)(4)

قال ابن حجر رحمه الله :
فالمراد هنا بالأخت : الأخت في الدِّين ، ويؤيده زيادة ابن حبان في آخره من طريق أبي كثير عن أبي هريرة بلفظ : (لَا تَسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا لِتَسْتَفْرِغ صَحْفَتهَا فَإِنَّ الْمُسْلِمَة أُخْت الْمُسْلِمَة) انتهى(5).

---

(1) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه-ص8 مع تصرف يسير.
(2) روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
(3) رواه الطبراني في الكبير (339/17) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (1934) .
(4) رواه البخاري (4857) - واللفظ له - ومسلم (1413) .
(5) " فتح الباري " (9 / 220) وحديث ابن حبَّان – (9 / 378) - صححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (تحت الحديث 2805) .

وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله :
في هذا الخبر من الفقه : أنه لا ينبغي أن تسأل المرأةُ زوجَها أن يطلِّق ضرَّتها لتنفرد به ، فإنما لها ما سبق به القدر عليها ، لا ينقصها طلاق ضرتها شيئاً مما جرى به القدر لها ولا يزيدها ."(1)
وجاء الحديث بلفظ : (أختها) ليثير في المرأة الشفقة والمحبة والعاطفة ، لأن الأخوة تقتضي المحبة والسعي فيما ينفع الأخت ، والبعد عما ضرها .
وإذا كانت الزوجة الأخرى تضر الزوج وتضر الأولاد ، ولا تصلح لأن يبقيها الزوج في عصمته ، فلا حرج على الزوجة الأخرى أن تقدم النصح للزوج بتطليقها .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
قوله : (لا يحل) ظاهر في تحريم ذلك ، وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوِّز ذلك ، كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة ."(2).

والحديث ظاهره أن المراد أختها الشقيقة، أو الأخت من أم، والقاعدة عند العلماء أن اللفظ يبقى على ظاهره ما لم تأت قرينة تصرفه، ولكن ليس المراد بأختها هنا الأخت النسبية والقرينة الصارفة لهذا الظاهر هي نصوص أخرى، (فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع المرء بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها).

وكذلك يصرف إرادة هذا الظاهر قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [النساء:23]، يعني: ليس لكم أن تجمعوا بين الأختين، وهذا النهي يكون صارفاً لظاهر الحديث أن يراد به الأخت النسبية.

بل المراد به أخوة الإسلام، ودليل إخوة الإسلام قول الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات:10]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (لو كنت متخذاً من البشر خليلاً لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الله، وإنما هي أخوة الإسلام).

فظهر بذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم.

فقد تكون المرأة شديدة الغيرة، وتكون ضرتها أجمل منها، أو ألطف منها، أو أحسن منها حديثاً، وألين تعاملاً مع زوجها، فيكون الزوج إذا دخل بيت الأولى يكتئب لكنه يتقي الله في أداء حقها، فإذا دخل بيت الأخرى ينشرح صدره، وتلمس المرأة الثانية ذلك منه، وهي أم أولاده عنده فتقول: لا بد من طلاقها أو طلاقي، أو لا بد أن تطلق الأخرى، فيقال لهذه: اتقي ربك فلا يجوز لك أن تفعلي ذلك.

فلو قالت: هاتوا الدليل من التقعيد الفقهي لا من الأثر، فيقال لها: إن القاعدة الفقهية تقول: لا ضرر ولا ضرار، وأنت بذلك توقعين الضرر بأختك في الإسلام، وتوقعي الظلم عليها، ولعلها إذا طلقها لا تجد غيره يسترها ويتزوج عليها، بل لعلها تموت بذلك، ولا يجوز إنزال الضرر ابتداء، ولا جزاء.

ونرد عليها أيضاً بأن الله قد أباح التعدد فلا يجوز أن تحرم ما أباحه الله، هذا سنقوله للتي طلبت الطلاق.

ونقول للأخرى: حتى لو أوقعت ضرتك بك الضرر فليس لك مقابلة الضرر بضرر.

---

(1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " (18 / 165) .
(2) " فتح الباري " (9 / 220) .

الفهرس

الموضوع	الصفحة
الإستهلال	1
الإهداء	**2**
شكر وتقدير	3
المقدمة	5-4
الفصل الأوّل وما يشتمله	6
القاعدة لغة	7
القاعدة اصطلاحا	8
الفقه في اللغة	9
الفقه في الإصطلاح	9
تعريف القاعدة الفقهيّة باعتبارها علما ولقبا	10
حجيّة القواعد الفقهيّة	12-11
الفصل الثاني وما يشتمله	13
تمهيد القاعدة	14
أهميّة القاعدة	14
الضرر لغة	15
الضرر اصطلاحا	16
شرح القاعدة اجمالا	16
أصل القاعدة	17
أقوال العلماء في الحديث	17
أدلّة القاعدة	19-18
القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة	20
القاعدة الأولى: الضرر يدفع بقدر الإمكان	20
القاعدة الثانية: الضرر يزال	20
القاعدة الثالثة: الضرر لا يزال بمثله	21
القاعدة الرابعة: الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخف	21
القاعدة الخامسة: يختار أهون الشرّين	22
القاعدة السادسة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما	22
القاعدة السابعة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام	23
القاعدة الثامنة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح.	25-24
القاعدة التاسعة: القديم يترك على قدمه	26
تطبيقات القاعدة	28-27

فهرس المراجع والمصادر

1- القرآن الكريم

2- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي

3- صحيح البخاري

4- صحيح مسلم

5- الموطّأ لإمام مالك

6- سنن الترمذيّ

7- سنن أبي داود

8- سنن ابن ماجة

9- صحيح ابن حبّان

10-مصنف ابن ابي شيبة

11- مصنّف عبدالرزاق

12- المعجم الكبير للطبراني

13-سبل السلام

14-نيل الأوطار

15-فتح الباري

16- عمدة القاري

17-عون المعبود

18-مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للحافظ البوصيري

19-التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.

20-المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري

21-السلسلة الصحيحة

22-مجموع الفتاوى

23-لسان العرب

24-معجم مقاييس اللغة

25-التعريفات

26-الكليّات لأبي البقاء الكفوي

27-والتوقيف على مهمّات التعاريف

28-المصباح المنير للفيومي.

29-غمر عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر

30-القواعد الفقهيّة

31-قواعد الفقه الإسلامي

32-تهذيب اللغة

33-الموسوعة الفقهية

34-كتاب غاية السول إلى علم الأصول

35-متن الورقات

36-كشف اصطلاحات الفنون
37-المواهب السنيّة
38-قواعد المقري
39-مجامع الحقائق (خاتمة في القواعد الفقهية
40-شرح جمع الجوامع للجلال الدين المحلي
41-شرح الكوكب المنير لابن النجار
42-كشّاف القناع للبهوتي
43-القواعد الفقهيّة الكبرى وما تفرّع عنها
44-الفروق للقرافي.
45-مجلة الأحكام العدليّة مع شرح علي حيدر المسمّى"درر الحكام شرح مجلة الأحكام."
46-المدخل الفقهي
47-إعلام الموقعين
48-الموافقات
49-المجموع المذهب
50-شرح القواعد الفقهيّة
51-شرح الأربعين النوويّة
52-الوجيز في ايضاح القواعد الفقه الكلية
53-الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية - المكتبة الشاملة الحديثة
54-كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للشيخ محمد مصطفى الزحيلي
55-قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ للعز بن عبدالسلام
56- الذخيرة للقرافي.
57-القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه.